

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제1절 부작위위법확인소송>

I. 부작위위법확인소송의 의의

1. 개념[행소법 제4조 제3호]

- 부작위위법확인소송이란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않은 경우(부작위)에 그 부작위가 위법함을 확인하는 소송을 말한다. 행정소송법 제4조 제3호에 규정되어 있다. 이 소송은 행정청의 응답 의무를 전제로 하며, 응답 의무가 있음에도 불구하고 아무런 응답을 하지 않는 소극적 위법 상태를 제거하는 것을 목적으로 한다.

2. 제도적 한계

- 부작위위법확인소송은 행정청에게 응답 의무를 이행하도록 강제하는 데 그 목적이 있을 뿐, 신청에 따른 특정한 처분을 하도록 강제하는 것은 아니다. 이는 법원이 행정청의 재량권 행사에 직접 개입하는 것을 자제하고, 권력분립의 원칙을 존중하기 위한 제도적 한계이다. 즉, 법원이 부작위가 위법함을 확인하는 판결을 내려도, 행정청은 인용 처분이나 거부 처분 중 어떤 응답을 할지에 대해서는 여전히 재량권을 가진다.

II. 부작위위법확인소송의 요건

- 부작위위법확인소송이 적법하려면 항고소송 일반의 요건 외에 부작위위법확인소송에 특유한 요건이 충족되어야 한다.

1. 대상적격

(1) 부작위의 성립

- 부작위가 성립하기 위해서는 당사자의 신청이 있어야 하며, 그 신청은 공법상의 신청이어야 한다. 또한, 행정청이 신청에 대하여 상당한 기간 내에 응답을 하지 않은 상태가 지속되어야 한다. 여기서 상당한 기간은 사회 통념상 행정청이 처분을 할 것으로 기대되는 합리적인 기간을 의미한다.

(2) 일정한 처분

- 부작위의 대상이 되는 행정작용은 일정한 처분이어야 한다. 즉, 그 행정작용이 행정소송법 제2조 제1항 제1호에 규정된 처분성을 가져야 한다. 처분성을 가지지 않는 행정작용을 구하는 신청에 대한 부작위는 이 소송의 대상이 될 수 없다.

(3) 법률상 의무

- 행정청에게 당사자의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재해야 한다. 이는 당사자에게 신청권이 있음을 의미하며, 신청권이 없는 자의 신청에 대한 무응답은 부작위위법확인소송의 대상이 될 수 없다. 신청권은 관련 법규의 해석에 의해 인정되어야 한다.

2. 당사자적격

(1) 원고적격

- 원고적격은 행정소송법 제36조에 규정되어 있다. 부작위위법확인소송은 처분등을 신청한 자로서 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 이는 부작위로 인해 법률상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에게 원고적격을 인정하는 것이다. 단순한 사실상의 이익이나 간접적인 이해관계만으로는 부족하다.

(2) 피고적격

- 피고적격은 행정소송법 제38조 제2항에 의해 제13조가 준용된다. 피고는 부작위 상태에 있는 행정청이 된다.

3. 기타 요건

(1) 행정심판전치주의

- 부작위위법확인소송에서도 행정심판전치주의가 적용되며, 이 경우 의무이행심판을 필요적으로 거쳐야 한다.

(2) 제소기간

① 행정심판을 거치지 아니한 경우

- 부작위는 계속되는 것이므로 부작위위법확인소송은 원칙상 제소기간의 제한을 받지 않는다고 보는 것이 타당하다.

② 행정심판을 거친 경우

- 판례는 행정심판을 거친 경우에는 행정소송법 제20조가 정한 제소기간 내(안 날로부터 90일, 있은 날로부터 1년)에 부작위위법확인소의 소를 제기하여야 한다고 한다.

(3) 재판관할[행소법 제38조 제2항, 제9조]

- 부작위위법확인소송의 재판관할도 취소소송과 마찬가지로 피고인 행정청의 소재지를 관할하는 행정법원을 제1심 관할법원으로 한다.

III. 부작위위법확인소송의 심리

- 부작위위법확인소송의 심리는 행정소송법 제38조 제2항에 따라 취소소송의 심리 규정들이 준용된다.

1. 심리의 기본원칙

- 부작위위법확인소송은 직권심리주의, 구술심리주의, 공개심리주의 등 취소소송의 심리 원칙이 그대로 적용된다. 법원은 당사자가 주장하지 않은 사항에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다.

2. 심리의 범위

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법한지 여부만을 심리한다.

(1) 위법성 판단 대상

- 법원은 행정청에게 응답 의무가 있음에도 응답하지 않은 부작위 자체의 위법성만을 심리한다.

(2) 본안 판단의 불가능

- 법원은 신청에 따른 응답한 처분(인용 처분)을 해야 할 것인지 여부 등 본안 사항에 대해서는 심리할 수 없다. 이는 사법부가 행정청의 재량권 행사에 직접 개입하는 것을 막는 권력분립 원칙의 존중 때문이다.

3. 입증책임

- 처분 등에 관한 입증책임 원칙이 준용되어, 원고가 부작위의 존재와 신청권의 존재 등 소송 요건에 관한 사실을 입증해야 한다. 반면, 피고인 행정청은 부작위가 적법하다는 사실(상당한 기간이 경과하지 않았거나 신청권이 없다는 등)을 입증할 책임이 있다.

4. 위법성 판단의 기준시

- 부작위위법확인소송은 행정청의 위법 상태가 계속되는 것을 다루는 소송이라는 특수성이 있다. 판례는 부작위의 위법성 판단의 기준 시점을 사실심 변론 종결 시로 본다. 이는 행정청의 응답 의무가 소송이 진행되는 중에도 계속되고, 법원이 소송 종료 시점까지의 행정청의 응답 여부 및 그 법적 상태를 포괄적으로 판단해야 하기 때문이다. 이는 처분 시를 기준으로 하는 취소소송과 구별되는 가장 큰 특징이다.

IV. 부작위위법확인소송의 종료

- 부작위위법확인소송은 법원의 판결, 소의 취하 등으로 종료되며, 판결의 효력은 취소소송 규정이 준용되지만 그 특성상 간접강제가 허용된다는 특징이 있다.

1. 법원의 판결

(1) 소송판결

- 소송 요건이 결여된 경우 법원은 각하판결을 내린다. 예를 들어 이미 거부 처분이 내려져 부작위 상태가 아닌 경우, 신청권이 없는 자가 제기한 경우 등을 들 수 있다.

(2) 인용판결

- 부작위가 위법하다고 인정될 때 법원은 인용판결을 내린다. 이 판결은 행정청에게 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 발생시킨다.

(3) 기각판결

- 부작위가 위법하지 않다고 인정될 때 법원은 기각판결을 내린다. 예를 들어 신청권이 없거나, 상당한 기간이 경과하지 않은 경우 등을 들 수 있다.

(4) 사정판결

- 취소소송의 제28조(사정판결)에 관한 규정이 부작위위법확인소송에 준용되지 않는다는 것이 일반적인 해석이다. 부작위의 위법성을 확인하는 판결을 공공복리라는 이유로 기각할 실익이 없기 때문이다.

2. 판결의 효력

(1) 기속력[행소법 제38조 제2항, 제30조]

- 부작위위법확인소송의 인용판결이 확정되면, 취소소송의 기속력에 관한 제30조가 준용된다. 법원의 위법 확인 판결의 취지에 따라 행정청은 지체 없이 이전에 신청받은 사항에 대해 응당한 처분을 해야 할 재처분 의무를 부담한다. 즉, 단순히 이전의 부작위 상태를 반복하거나 단순한 무의미한 거부 처분만을 반복해서는 안 된다.

(2) 간접강제[행소법 제38조 제2항, 제34조]

- 부작위위법확인소송의 경우 인용판결에도 불구하고 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 때, 행정소송법 제38조 제2항은 제34조(간접강제)를 준용한다. 법원은 신청에 따라 결정으로 상당한 기간을 정하고, 행정청이 그 기간 내에 처분을 하지 않으면 지연 기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명할 수 있다. 이는 판결의 실효성을 확보하기 위한 강력한 수단이다.

(3) 제3자효[행소법 제38조 제2항, 제17조, 제31조]

- 제3자효에 관한 규정은 부작위위법확인판결에 대하여도 준용된다. 판결의 효력이 제3자에게도 미치므로 제3자를 보호하기 위하여 제3자의 소송 참가제도와 제3자의 재심청구제도도 준용된다.

3. 재심[행소법 제38조 제2항, 제31조]

- 부작위위법확인소송의 확정 판결에 중대한 하자가 있는 경우, 취소소송의 제31조가 준용되어 재심을 청구할 수 있다. 재심 사유는 민사소송법 제451조의 규정을 따른다.

V. 가구제

1. 집행정지

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위를 대상으로 하므로, 처분의 효력이나 집행이 존재하지 않는다. 따라서 취소소송에서 인정되는 처분의 효력 정지를 목적으로 하는 집행정지는 성질상 인정되지 않는다.

2. 가처분

- 부작위위법확인소송은 행정청의 응답을 강제하는 소송이지만, 행정소송법상 가처분에 관한 명문 규정이 없으므로, 판례의 태도에 따라 가처분은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만, 학설은 부작위가 계속될 경우 회복하기 어려운 손해가 발생하는 예외적인 경우에 한하여 잠정적인 조치를 위해 가처분을 인정해야 한다는 주장을 제기하기도 한다.

VI. 청구의 병합과 소의 변경

1. 관련 청구소송의 병합 및 이송[행소법 제38조 제2항, 제10조]

- 부작위위법확인소송에도 취소소송의 제10조가 준용되어 관련 청구소송의 병합 및 이송이 허용된다. 관련 청구소송에는 부작위로 인한 손해에 대한 손해배상 청구 등이 포함될 수 있다.

2. 소의 변경

- 행정소송법 제37조에 따라 부작위위법확인소송을 다른 항고소송(거부처분 취소소송)으로 소의 변경이 허용된다.

(1) 부작위위법확인소송에서 거부처분 취소소송으로의 변경

- 부작위위법확인소송이 계속되는 도중에 행정청이 거부 처분을 한 경우, 원고는 부작위위법확인소송을 거부처분 취소소송으로 변경할 수 있다. 이는 행정소송법 제22조(처분 변경으로 인한 소의 변경)와 제37조에 근거를 둔다.

(2) 변경의 효과

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 허용되며, 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다.

VI. 결론

- 부작위위법확인소송은 행정청의 응답 의무 불이행에 대한 위법성만을 심리하는 소송으로서, 신청권과 처분성이 소송 요건의 핵심이다. 취소소송과 달리 위법성 판단의 기준 시점은 사실심 변론 종결 시로 본다. 판결의 효력과 관련하여 기속력과 간접강제가 준용되어 재처분 의무 이행의 실효성이 확보된다는 특징을 가진다.